

1501378-31.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... fls. 88/90. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Sergio Alexandre Soares Franzin, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento em local já conhecido pelo trafico de drogas quando avistaram o acusado entregando algo para outro individuo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501378-31.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001014

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238928/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 19999513 - 02º D.P. PIRACICABA, 3409/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2238928 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON DE OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Aos 25 de janeiro de 2022, às 15:45h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: JACKSON DE OLIVEIRA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC SÉRGIO ALEXANDRE SOARES FRANZIN - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA - AUSENTE

Testemunha comum: JELIEL BARBOSA DE LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha SÉRGIO ALEXANDRE SOARES FRANZIN.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia das oitivas das

testemunhas GC JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA e JELIEL BARBOSA DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra ao Dr. Promotor, por ele foi dito que desistia das oitivas das testemunhas GC JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA e JELIEL BARBOSA DE LIMA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu JACKSON DE OLIVEIRA SILVA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "JACKSON DE OLIVEIRA SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 78/81. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 99), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 103/106), sendo a denúncia recebida (fls. 112/115). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, fotografia de fls. 15 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 88/90. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Sergio Alexandre Soares Franzin, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento em local já conhecido pelo trafico de drogas quando avistaram o acusado entregando algo para outro individuo. Ao verem a viatura, cada um dos indivíduos foi para um lado e o réu, ao atravessar a rua, dispensou um caixa de cigarro e uma certa quantia em dinheiro. O réu foi abordado e com ele nada de ilícito foi localizado, porem dentro caixa de cigarro por ele dispensada encontraram 3 pinos de cocaína, 8 porções de maconha e 19 pedras de "crack". Questionado, JACKSON confessou que a droga é de sua propriedade e estava no local traficando. Quanto ao outro indivíduo que estava no local, com ele foram localizados 02 pinos dentro de sua boca e ele confessou que havia acabado de comprar de JACKSON, pagando R\$ 20,00. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal José Antônio de Souza Oliveira, ouvido apenas na fase inquisitiva. Jeliel Barbosa de Lima, a seu turno, ouvido também apenas na fase policial, disse perante a autoridade policial que foi até o local dos fatos, que é ponto conhecido de tráfico de drogas, para comprar cocaína para seu próprio uso. Ali encontrou a pessoa de JACKSON e adquiriu dois eppendorfs de cocaína por R\$ 10,00 cada. Neste momento, a viatura da Guarda Municipal virou e os flagrou. Disse que JACKON jogou tudo que estava em suas mãos e atravessou a rua enquanto ela, a testemunha, permaneceu no local. Os guardas abordaram JACKSON e posteriormente o abordaram, entregando-lhes dois pinos de cocaína, que estavam em sua boca. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que estava no bar juntamente com sua esposa e foi pedir ao dono do bar para levar sua esposa no hospital, momento em que a viatura da Guarda chegou. Negou a propriedade das drogas apreendidas e negou ter vendido drogas à testemunha, alegando que no momento em que a viatura chegou estava com sua esposa e o dono do bar, chamado Neguinho. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo, sendo certo que sequer sua mulher e o dono do bar, por ele mencionados, os quais poderiam dar algum supedâneo à sua versão, foram ouvidos como testemunhas de defesa, evidenciando assim a falácia de suas palavras. Outrossim, é certo que o guarda municipal ouvido foi claro e uníssono ao afirmar que viram o momento que o acusado entregou algo ao outro individuo, bem como que o viram jogar o maço de cigarro, onde estavam os entorpecentes, ao

atravessar a rua. Foi claro também ao afirmar que o acusado confessou informalmente o tráfico e que o usuário confirmou que havia acabado de comprar drogas com o réu, circunstância que foi confirmada pelo usuário Jeliel perante a autoridade policial. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente específico (autos nº 1500274-72.2019 - fls. 82/83). Na terceira fase, ante a reincidência específica, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 30,00 (trinta reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreu de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de

atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Sérgio, GCM, declarou que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu entregando um objeto para um segundo indivíduo. No momento em que eles visualizaram a viatura, eles ficaram nervosos e o réu começou a atravessar a rua e dispensou um objeto ao solo, posteriormente identificado como uma embalagem de cigarros. Ele também dispensou uma quantia em dinheiro (R\$ 30,00). Efetuaram a abordagem do réu e do outro indivíduo. Com o réu, nada de ilícito foi encontrado. Porém, recuperaram a embalagem e verificaram que, no interior, havia algumas porções de entorpecentes. O acusado confessou informalmente o tráfico de drogas. Com o Jeliel encontraram, dentro de sua boa, duas porções de entorpecentes. Ele disse que havia comprado as drogas do réu, pelo valor de R\$ 20,00. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que estava no bar do Neguinho com sua esposa, conversando e jogando bilhar. Foi falar com o dono do bar e pedir para ele levar sua esposa ao Hospital, sendo que ela tinha horário marcado. Nesse momento, os Guardas chegaram e abordaram o outro indivíduo. Em seguida, os Guardas lhe abordaram e disseram que o Jeliel falou que tinha comprado drogas do réu. As drogas eram no Matheus Henrique. Ele é o responsável pelo tráfico no local. Conhecia os Guardas Municipais, eles já invadiram a sua residência em momento anterior e lhe disseram que, antes do Natal, ele seria preso novamente. Estava em frente ao bar, com o Neguinho e sua esposa. Não conhecia o Jeliel. O ponto de tráfico fica em outro local, não no bar do Neguinho. Não dispensou nenhum objeto. Não portava nem dinheiro. O Diego Silveira e o Patrick Galhardo também são envolvidos com o tráfico de drogas no local. Quem vende as drogas são eles. Eles permanecem ali todo dia. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais

evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e, embora os agentes mencionem que teriam avistado o acusado “negociando algo” com o Senhor Jeliel, não é possível afirmar, com certeza, que se tratava de um ato de mercancia de entorpecentes, até pela distância em que os Guardas se encontravam. Além disso, os entorpecentes, na realidade, não foram localizados sob a posse direta do réu, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E, a despeito das declarações do Senhor Jeliel na Delegacia de Polícia, o seu depoimento, na realidade, não foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, eventual confissão informal do acusado aos Guardas Municipais, além de constituir uma circunstância aberrante, que destoa do ordenamento jurídico, não foi confirmada no interrogatório do réu. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado

Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

JACKSON DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 13h50min, na Dolores Moral do Satto, nº 689, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, vendeu para Jeliel Barbosa de Lima, 02 (dois) eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 0,36g (trinta e seis decigramas), bem como trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 03 eppendorfs de cocaína em pó, pesando cerca de 0,54g (cinquenta e quatro decigramas), 08 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 9,5g (nove gramas e cinco decigramas), e 19 (dezenove) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 2,1g (dois gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado e Jeliel negociando algo na via pública. Ao visualizar a aproximação da viatura, JACKSON atravessou rapidamente a rua e dispensou uma caixa de cigarros e a quantia de R\$ 30,00 em espécie defronte ao "Bar do Neguinho". Em razão disso, os agentes públicos procederam à abordagem de JACKSON e Jeliel e apreenderam na posse deste, especificamente dentro de sua boca, 02 eppendorfs de cocaína. Ato contínuo, os guardas recuperaram a caixa de cigarros dispensada pelo acusado e constataram que em seu interior havia 03 eppendorfs de cocaína, 08 porções de maconha e 19 porções de "crack". Indagados, Jeliel afirmou que acabara de comprar os eppendorfs de cocaína apreendidos em sua posse de JACKSON pela quantia de R\$ 20,00, o qual, por sua vez, confessou a prática delitiva, confirmando que toda a droga localizada era de sua propriedade e que estava no local traficando. O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 99) e apresentou defesa preliminar (fls. 103/106), seguindo-se a decisão de fls. 112/115, que recebeu a denúncia.

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 15 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 88/90, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do ato de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 06/07)

Em juízo, negou a prática do crime. Afirmou que tinha acabado de sair da cadeia e estava no bar com sua esposa. Declarou que conversou com o dono do bar, para perguntar para ele se podia levar sua esposa, grávida, a uma consulta. Então, os guardas chegaram e abordaram um outro rapaz, que ele não conhecia. Após, foi abordado e os policiais disseram que a droga era sua, o que não é verdade. Disse que o dono da biqueira ali é o Mateus Henrique, que mora ao lado do bar. Aduziu que ele mesmo vende a droga, juntamente com Diego Silveira Patrick Galhado.

A prova acusatória, porém, é maciça e incriminadora.

O guarda municipal Sérgio relatou que estavam em patrulhamento em local já conhecido como ponto de tráfico e, quando entraram na rua, viram o réu entregando algo a outro indivíduo. Atestou que, ao verem a viatura, eles demonstraram nervosismo e cada um foi para um lado, sendo que o réu atravessou a rua e jogou algo ao solo, posteriormente identificado como sendo uma embalagem de cigarro. Disse que ele também dispensou uma quantia em dinheiro, R\$ 30,00. Afirmou que ambos foram abordados. Com o réu, nada encontraram, mas apuraram que, na embalagem de cigarro, havia algumas porções de entorpecentes, 19 pedras amareladas, 8 porções de maconha e 3 pinos de cocaína. Aduziu que ele admitiu que estava na prática de tráfico e, com o outro indivíduo, na boca, encontraram duas porções de cocaína, que ele disse ter adquirido do réu por R\$ 20,00.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal José Antônio (fls. 03).

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas

municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o guarda assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Enfim, o fato de os policiais terem flagrado o réu na via pública, negociando algo com outro indivíduo e, após, dispensando uma caixa no chão ao notar a aproximação da viatura, vindo a apreender dois eppendorfs de cocaína em poder desse outro indivíduo, e 03 eppendorfs de cocaína, 08 porções de maconha e 19 porções de "crack", no interior da caixa que o réu havia dispensado no chão, conduz à certeza quanto à autoria e a traficância.

Anoto que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados às circunstâncias da apreensão, deixam evidente que a droga se destinava mesmo ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu nos termos da denúncia.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é reincidente específico (cf. certidão de fls. 82/84). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, aumento-a de um sexto, por ser o réu reincidente, inclusive, específico (autos 1500274-72.2019 da 1ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 82/84), resultando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes. Inexistem causas de aumento. De outro lado, o réu não faz jus à redução da pena

prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o réu reincidente específico e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu JACKSON DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é

24/01/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]